

1500825-36.2021.8.26.0129

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... G. Strenger - julgado em 04/09/2019).

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câmara, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500825-36.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500825-36.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2327518/2021 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 15900435 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 1170/21/203 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2327518 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, sendo-lhe imputado o crime do art. 33, caput, c/c art, 40, III, ambos da Lei 11.343/06. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 09h02min, na Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, o réu adquiriu e recebeu, para fins de entrega a consumo de terceiros, no interior de penitenciária estadual, porções de maconha, pesando 54,2g (cinquenta e quatro gramas e dois decigramas) e porções de cocaína, pesando 32,7g (trinta e dois gramas e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu apresentou defesa prévia às fls. 162/163.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022.

O réu foi citado às fls. 109/191.

Realizada audiência de instrução, as testemunhas arroladas foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, apresentadas oralmente, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua, vez apresentou suas alegações finais por meio de memoriais escritos às fls. 197/201.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do fato restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/7), pelos autos de exibição e de apreensão (fls. 19 e 20), pela declaração de compromisso e responsabilidade (fl. 12), pela fotografia da embalagem em que constam dados do remetente e local de postagem nos Correios (fl. 21), pelos laudos dos exames químicos-toxicológicos (fls. 23/25 e 27/28), pelas declarações da mãe do acusado (fl. 35) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

PAULO DA SILVA FERREIRA, agente penitenciário, em juízo, informou que trabalha no setor de inclusão da penitenciária local, sendo o responsável pela entrega de encomendas aos sentenciados. As encomendas via SEDEX enviadas aos sentenciados são recebidos na unidade prisional pelo setor de portaria, onde se verifica se o remetente é autorizado ao envio. Em sendo regular o remetente, a encomenda é encaminhada ao setor de inclusão. No setor de inclusão, os sentenciados são chamados e indicam quem é o remetente, qual o grau de parentesco e se aceitam o recebimento. No caso dos autos, foi informado a FERNANDO quem era o remetente. Ele, então, confirmou se tratar da mãe, o nome dela e a cidade. Nesta oportunidade, disse a ele que a cidade era diferente. Mesmo assim, ele aceitou receber a encomenda, assinou o termo de responsabilidade e autorizou a abertura da encomenda. Ele pôde visualizar o pacote e a grafia lá constante. Abriu a embalagem e fez a vistoria. Dentre os itens, existiam 14 embalagens de fumo desfiado. Nestas, havia um invólucro dentro de cada (era uma espécie de "bexiguinha"). Localizou MACONHA em dez e COCAÍNA em quatro. Indagado, ele ficou em silêncio. Não sabe a respeito de suspeitas do envolvimento dele com drogas na unidade. Foi um procedimento de rotina. Foi informada a ele a divergência entre o endereço do remetente e o local de postagem. Mesmo diante desta informação, ele aceitou o recebimento.

EMERSON ANTÔNIO AUGUSTINHO, agente penitenciário, manifestou-se no mesmo sentido de seu colega. Acrescentou que foi avisado a FERNANDO que o endereço declarado e escrito pelo remetente e aquele constante do carimbo dos Correios eram de diferentes cidades. Ele, ciente desta divergência, aceitou receber a encomenda sem qualquer ressalva. Foi um encontro normal e rotineiro em revista de encomendas SEDEX. Não tem conhecimento de qualquer suspeita anterior que recaía sobre o réu.

FÁBIO GIZZE DE MARQUE, diretor de segurança e disciplina, relatou que não estava presente na apreensão em si, mas lhe informado posteriormente da localização de MACONHA e de COCAÍNA. Não tinha informação vinculando ele ao tráfico de drogas na unidade. Sabe que a guarda de MACONHA junto a fumo é um método comumente utilizado para se tentar disfarçar o cheiro. A sindicância concluiu que houve falta disciplinar por parte do sentenciado, notadamente diante da postagem em cidade e estado diferentes do familiar remetente e da possibilidade de recusa da encomenda.

FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, em seu interrogatório, afirmou que não era o destinatário do SEDEX. Não se importou com a divergência de cidades, pois o remetente era sua mãe. Quando foi aberto, viu que alguns itens eram os comumente enviados por sua mãe, mas viu que tinha grande quantidade de fumo desfiado.

Contudo, já tinha assinado o termo de responsabilidade e não tinha como voltar atrás. Percebeu a divergência de cidades. Apenas não se importou, uma vez que sua mãe poderia ter viajado. Tem muitos inimigos no cárcere e as cartas, com seus dados, ficam expostas por não existir local adequado para guardar. Poderia ser facilmente incriminado. Não tem motivo para praticar o tráfico. Não pediria o envio de drogas por meio de SEDEX, sabendo que todas as encomendas passam por revista. Analisando-se a pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a presente ação penal é procedente, sendo de rigor a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A negativa do réu está isolada frente aos demais elementos de provas trazidos aos

autos.

Por outro lado, as palavras dos agentes penitenciários merecem crédito.

De fato, são servidores públicos, selecionados e empossados mediante concurso público, nos quais o Estado deposita confiança para desempenho do mister.

Seria verdadeira contradição o mesmo Estado, agora na função jurisdicional, afastar ou diminuir o valor das palavras dos agentes públicos que apuraram os fatos.

Saliento que nada nos autos indica o desejo dos servidores de imputar conduta tão grave ao réu de maneira inverídica. Nesse sentido, exemplo da farta jurisprudência:

“As palavras dos agentes penitenciários e do chefe de segurança do presídio devem ser acatadas, pois são servidores públicos, nada indicando desejo de imputar condutas tão graves aos réus de maneira leviana. Nesse sentido, exemplo da farta jurisprudência: E esses testemunhos, aliados às condições em que se deu a apreensão do entorpecente, não deixam dúvida quanto à intenção de praticar a traficância no interior do estabelecimento prisional. Não é, outrossim, de suspeitar-se da narrativa dos agentes penitenciários, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha”. (Apelação nº 0004237-69.2012.8.26.0483 - Comarca: Presidente Venceslau Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Criminal- Relator Ivan Sartori).

“Vale ressaltar que os relatos dos agentes penitenciários envolvidos na apreensão das drogas são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis”. (Apelação nº 1501774-69.2018.8.26.0548 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. César Augusto Andrade de Castro - julgado em 04/12/2019).

De fato, ao receber a correspondência - que constava como remetente sua mãe e o endereço em Barrinha-SP (fl. 21) - o acusado assumiu a propriedade dos produtos existentes em seu interior, no momento em que assinou o termo de responsabilidade (fl. 12), aderindo à conduta da pessoa que enviou as drogas.

Ademais, o acusado foi informado da divergência entre o endereço do remetente (Barrinha-SP) e o local de postagem (Arceburgo-MG). Ressalta-se que tal divergência está claramente indicada na "declaração de compromisso e responsabilidade". Não bastasse, a mãe do acusado afirmou que jamais esteve em Arceburgo-MG (fl. 35). Como se vê, o réu assumiu claramente o risco de produzir o resultado, pois se responsabilizou pelo conteúdo do pacote, ou seja, recebeu as drogas enviadas ao presídio. Ora, trata-se de sentenciado por delito de tráfico de drogas, inserido junto ao sistema penitenciário há anos, que sabe como funciona o ingresso de produtos via sedex: se aceitou receber a encomenda, mesmo tendo visto que o local de postagem divergia do local onde sua mãe reside, sinal que desejava obter o conteúdo espúrio do pacote, fato que se compreende frente ao valor que as drogas alcançam no interior dos estabelecimentos penais.

De fato, o valor da droga apreendida (mormente no interior de um presídio) retira a verossimilhança da hipótese de que um desafeto teria enviado o Sedex somente para prejudicar o acusado. Não é possível crer que o réu desconhecesse o conteúdo ilícito da correspondência, supostamente enviada por sua mãe. Assim o conluio entre o réu e o remetente é nítido. Também não há que se falar em mero equívoco.

Claro está que o réu era o destinatário das drogas apreendidas e que estas seriam distribuídas no interior do estabelecimento prisional local. Nada nos autos indica plausibilidade da alegação formulada pelo acusado de que terceira pessoa enviou as drogas para prejudicá-lo, visto que ao se responsabilizar pelo conteúdo, aderiu à conduta daquele que enviou drogas ao interior de um estabelecimento prisional que conta com mais de dois mil reeducandos.

Partindo do princípio que adotado em nosso sistema como regra, em matéria de

concurso de pessoas, segundo a qual todos aqueles que concorrem para a prática delituosa respondem pelo delito praticado, na medida de sua responsabilidade, de rigor a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, visto que embora não tenha podido praticar a conduta de entregar a droga a terceiros como pretendido, participou da conduta de tráfico praticada pelo remetente ao fornecer os dados pessoais de sua mãe, que figurou como remetente.

Sobre o tema:

"O denunciado concorreu com o crime ao passo que se ajustou previamente com indivíduo desconhecido, para que remetesse ao estabelecimento prisional os entorpecentes. (...) Demais disso, ao contrário do invocado pela defesa, cedejo que o réu tinha ciência acerca do recebimento da mercadoria proscriita, eis que o item foi encaminhado mediante a utilização de dados de pessoa cadastrada em seu rol de visitas, situação por ele ajustada, sendo notória a audácia em sua conduta, eis que, conhecedor dos procedimentos de revista, tentou burlar o sistema de segurança do Poder Público". (Apelação nº 1500316-36.2018.8.26.0283 – 8ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Sergio Ribas – julgado em 24/10/2019). Grifei.

Nesse sentido é o ensinamento de Cezar Roberto Bittencourt:

"Coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal. Coautoria é em última análise a própria autoria⁵⁶. É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum. É, portanto, a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando o caráter de crime único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime..". (Bittencourt, Cezar Roberto Tratado de direito penal: parte geral – 17. ed. rev., ampl. e atual – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 552).

A finalidade da traficância é nítida, considerando a forma com que acondicionadas as drogas, ocultadas no interior de pacotes de fumo, e a considerável quantidade de entorpecente apreendido (54,2 gramas de maconha e 32,7 gramas de cocaína), notadamente no interior de um estabelecimento prisional.

Ponto que a droga no interior dos presídios alcança valor exponencialmente maior que nas ruas, dada a dificuldade de ingresso das substâncias. Nesse passo, clara está a relevância das drogas apreendidas nestes autos.

Por fim, para que se acolhesse a tese da defesa no sentido da insuficiência de provas para decretar a condenação, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela fala dos agentes.

Sem isto, ou seja, sem que haja contraprova à aquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por testemunhas policiais, há de se aceitar a veracidade dos depoimentos prestados pelos agentes da lei.

Consigno, por oportuno, que a vistoria nas correspondências e encomendas, ainda que minuciosa, dificulta a entrada de entorpecentes na penitenciária, mas não a torna impossível. Do contrário, não haveria tantos procedimentos de igual natureza no sistema prisional e jamais se localizaria drogas nas celas.

Além disso, o crime se consumou nas modalidades adquirir e receber, do que se extrai que antes mesmo da apreensão das drogas pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado, sendo desnecessário que as drogas de fato ingressassem no presídio. Esse tem sido o entendimento das Câmaras de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em casos análogos:

"Inicialmente, buscam os Apelantes suas absolvições, aduzindo se tratar de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio, isso porque a existência de scanner no

estabelecimento prisional impediria, de qualquer forma, a consumação do crime. Para caracterização de crime impossível, é necessário não existirem meios de o agente conseguir chegar à consumação do crime, o que não ocorreu no caso dos autos. O fato do estabelecimento prisional possuir um scanner na revista, o que impediria o ingresso de materiais não permitidos, não é garantia de que JULIANE não conseguiria atingir seu intento". (Apelação nº 1500429-58.2019 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Luís Antônio Cardoso - julgado em 03/12/2019).

"Ademais, a conduta é típica, ainda que o apelante não tivesse conseguido efetivamente tomar posse da droga dentro do presídio. Desta forma, sendo o tráfico de drogas um tipo penal de conteúdo misto alternativo, qualquer das condutas descritas em seu preceito primário tipifica o delito". (Apelação nº 1500321-58.2018.8.26.0283 - 3ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Tozola Neto - julgado em 02/12/2019).

"Ademais, não se exige prova de que alguma pessoa tenha efetivamente adquirido entorpecente do acusado, eis que, para a caracterização do tráfico, não é necessário que o indivíduo esteja praticando algum ato de mercancia, bastando que exista apenas uma das condutas previstas pelo art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar de crime de ação múltipla. Ou seja, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, adquirir e remeter entorpecentes para consumo de terceiros, o que no caso restou comprovado". (Apelação nº 1501687-79.2018.8.26.0624 - 11ª Câmara de Direito Criminal- Relator Des. Guilherme G. Strenger - julgado em 04/09/2019).

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, 1ª Câmara, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).

Pelo exposto, impossível a absolvição pleiteada pela Douta Defesa, vez que configurada a autoria do réu no delito de tráfico que, mesmo tendo visto o local de postagem, aceitou a encomenda e assinou o termo de responsabilidade, ciente de que poderia recusá-la, caso vislumbrasse alguma irregularidade, o que não fez. Assim, suficiente a prova testemunhal, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime de tráfico de drogas por conta do agente como indicado na denúncia.

Atribuída a responsabilidade, passo à dosimetria da pena.

De início, é de se notar que, consoante certidão de distribuição criminal carreada às fls. 139/145, o réu ostenta cinco condenações criminais transitadas em julgado: (i) Foro de Piracicaba, 2ª Vara Criminal, 1501644-52.2020.8.26.0599 - 0004351-51.2021.8.26.0496, data do fato: 28/12/2020, art. 157 § 2º, Parte A, I c/c art. 157 § 2º, II c/c art. 29 "caput" todos do(a) CP, trânsito em julgado em 08/11/2021; (ii) Foro de Ribeirão Preto, 5ª Vara Criminal, 0001051-52.2016.8.26.0530 - 0008885-32.2017.8.26.0026, data do fato: 02/09/2016, art. 155 § 4º, I, IV c/c art. 14, II ambos do(a) CP, trânsito em julgado em 10/12/2018; (iii), Foro de Ribeirão Preto, 3ª Vara Criminal, 0001236-65.2016.8.26.0506, data do fato: 20/01/2016, art. 33, § 4º do(a) SISNAD, trânsito em julgado em 23/06/2016; (iv) Foro de Sertãozinho, 1ª Vara Criminal, 0005265-55.2011.8.26.0597, data do fato: 13/05/2011, art. 155 § 4º, II do(a) CP, trânsito em julgado em 10/07/2017; (v) Foro de Sertãozinho, 1ª Vara Criminal, 3000352-08.2013.8.26.0597, data do fato: 03/10/2013, art. 157 § 2º, II do(a) CP, trânsito em julgado em 22/03/2016.

É, portanto, reincidente e portador de maus antecedentes, o que será desvalorado tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria penal.

Na primeira fase, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase incide a agravante da reincidência, motivo por que elevo a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, por conta do disposto no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 para fixá-la em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses e 08 (oito)

dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, a qual torno definitiva.

Outrossim, deixo de aplicar a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006 por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, em consideração aos maus antecedentes e à reincidência.

Igualmente, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, em razão do montante da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão no regime inicial fechado e de 793 dias-multa, estes fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos

Em respeito ao princípio da contemporaneidade (art. 315, §1º do CPP), não há razão para o decreto de segregação cautelar nestes autos, em que pese a gravidade em concreto do delito.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Tendo em vista que não existem dúvidas sobre a natureza e quantidade das substâncias, tampouco acerca da regularidade dos laudos toxicológicos, determino a destruição por incineração das drogas apreendidas, preservando-se amostras mínimas necessárias para eventual contraprova (art.58, §1º c/c art.32, § 1º da Lei nº 11.343/06).

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, no valor máximo, em prol do ilustre patrono que atuou no feito em função do convênio da assistência judiciária. Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da multa (art. 50, caput do CP); (4) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

P.I.C.

Casa Branca, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA